

1500548-47.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500548-47.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500548-47.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

BRUNO DOS SANTOS SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GABRIEL MOROZESKY PIMENTA e BRUNO DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso(s) I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 2h30, na Avenida Capitão Francisco César, 140, nesta cidade e comarca de Barueri, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo tentaram subtrair para si 3 aparelhos de som, 8 cortadores de unha, 4 baralhos, 1 martelo, 50 pilhas, 11 bonés, 12 óculos de sol, 1 lâmpada de led e 26 relógios de pulso, avaliados globalmente em R\$1.200,00, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em 11 de outubro de 2018 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 68/70).

Auto de exibição e apreensão nas fls. 6/7; auto de entrega nas fls. 26/27.

A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2019 (fl. 98).

Em 30 de agosto de 2019 foi concedida a liberdade provisória aos réus (fls. 191/192).

Os réus foram citados (fls. 113 e 222) e apresentaram defesa preliminar (fls. 120 e 246). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 247). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados. As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

Os réus foram denunciados pela Promotoria de Justiça como incurso no artigo 155, § 4º, inciso(s) I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 2h30, na Avenida Capitão Francisco César,

140, nesta cidade e comarca de Barueri, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo tentaram subtrair para si 3 aparelhos de som, 8 cortadores de unha, 4 baralhos, 1 martelo, 50 pilhas, 11 bonés, 12 óculos de sol, 1 lâmpada de led e 26 relógios de pulso, avaliados globalmente em R\$1.200,00, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Foi apenas parcialmente comprovada a materialidade do delito. Já foi requisitado e reiterado à autoridade policial que remetesse o laudo de exame do local, que poderia comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo (fls. 191/192; 225; 250). Nesta data, em pesquisa ao sistema da polícia científica não localizei o documento e como nunca sobreveio resposta, ainda que sob a forma de justificativa, às requisições do juízo, compreendo que não foi mesmo produzido.

Nesse panorama, e em atenção ao teor do artigo 158 do CPP, que estabelece a prova pericial como imprescindível quanto a crimes não transeuntes, o caso é de afastar a qualificadora correspondente ao rompimento ou destruição de obstáculo. De acordo com o preceito legal, nem mesmo a confissão poderia suprir a falta da perícia e não cogito fosse o caso de dispensá-la, porque a única exceção legal é relativa ao vestígio naturalmente efêmero, mas não era o caso dos autos. Bastaria que a polícia tivesse preservado o local e enviado equipe técnica para realização da perícia tão cedo quanto possível. Se isso não ocorreu por falta de atenção na condução das diligências iniciais ou se por falta de recursos, o fato é que a prova não foi produzida e a consequência processual é o rechaço da circunstância que por meio dela teria de ser demonstrada.

No mais, a existência do crime é certa e a autoria também, ante as provas coligidas nas duas fases da persecução.

Com efeito, na fase policial os réus confessaram a prática delitiva, sem ressalvas. Quebraram as portas da loja e separaram mercadorias diversas, as quais pretendiam vender para adquirir entorpecentes. Foram detidos antes de deixar a loja com a sacola de produtos.

O réu Bruno foi interrogado em juízo e novamente confessou a prática do crime, inclusive quanto ao arrombamento e ao concurso de pessoas.

As testemunhas Clayton e Jairo e declararam nas duas fases da persecução penal que são policiais militares e na data do fato foram avisados de um furto em curso no local; acorreram ao ponto informado, uma loja guarneçada de portas de duas portas, uma de vidro, outra metálica. No interior do estabelecimento em desordem estavam os dois réus e junto deles uma sacola de lona contendo produtos diversos. Na ocasião, os réus disseram que iriam subtrair e vender os objetos para comprar drogas.

A vítima Francisco disse na polícia e em juízo que na noite do fato estava em casa e foi informado por telefonema de vizinhos a respeito da invasão em sua loja. Foi até o local, onde encontrou os policiais e os réus ainda dentro do estabelecimento. Lembrou em juízo que havia mercadorias separadas dentro de sacos para fins de subtração e que muitas delas foram perdidas por estarem sujas com sangue, dado o arrombamento que eles tinham realizado.

Entendo que deve ser reconhecida a majorante do §1º do artigo 155 porque o fato comprovadamente ocorreu durante o repouso noturno. Constatou-se a denúncia que os fatos se deram à noite, por volta das 2 horas e isso foi confirmado pela prova oral. O fato de não ter sido capitulada ao final da denúncia a causa de aumento não impede que a incidência seja reconhecida pelo juízo na sentença, a teor do artigo 383 do CPP.

Não acolho a alegação defensiva de que essa majorante não poderia ser aplicada porque haveria câmeras de segurança no local, uma vez que a jurisprudência já se orienta há algum tempo no sentido de que ela deriva, ou seja, sua mens legis diz respeito à menor vigilância das pessoas, em geral, pouco importando que, no imóvel em que ocorreu o crime haja algum tipo de vigilância.

Passo à dosagem da pena.

O artigo 155, § 4º, do Código Penal estabelece pena-base de 2 a 8 anos de reclusão, e multa.

Lembro que remanesce no caso somente a qualificadora correspondente ao concurso de agentes, nos termos mais acima expostos.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem

consideradas em relação ao réu Bruno, por isso fixo a pena-base no mínimo legal. O corréu Gabriel, por outro lado, tem maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0008752 40 2016, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, trânsito em julgado operado em 30/11/2016 e nos autos 0071490 73 2016, que tramitaram perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, condenação que se tornou definitiva em 25/06/2019 (fls. 187/188).

O segundo apontamento refere-se a fato ocorrido antes do evento sob exame nestes autos, em 24/08/2016, conquanto a questão só tenha sido definitivamente julgada durante o trâmite deste feito.

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014).
(...)"
(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Destarte, fixo a pena-base para o réu Gabriel em 2 anos e 6 meses de reclusão em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 545 do STJ, e da menoridade de 21 anos de idade do réu Gabriel na data do evento. Concorre a agravante da reincidência, pois ele foi condenado definitivamente em 30/11/2017, nos autos 0000097 97 2017, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 188). A reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal.

É verdade que o réu Gabriel confessou a prática do crime apenas em juízo, mas como são duas as atenuantes, compenso as circunstâncias, permanecendo a pena no patamar fixado anteriormente, 2 anos e 6 meses de reclusão.

Permanece inalterada também a pena do réu Bruno, que foi fixada no mínimo legal e não pode agora ser reduzida aquém desse patamar em razão da atenuante da confissão, a teor da súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena está presente a causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno, que é de 1/3. Também deve ser levada em conta a tentativa e de acordo com o artigo 14 do Código Penal, a redução em razão disso deve ser de 1 a 2/3. No caso, considerando que os réus avançaram bastante no iter criminis, chegaram a separar dentro do estabelecimento uma série de objetos que pretendiam subtrair, entendo que a redução proporcional é o patamar mínimo.

Efetuada em primeiro lugar o aumento, a pena privativa de liberdade passa a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão para o réu Bruno. Para o réu Gabriel, 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

A pena de multa deve seguir os mesmos delineamentos expostos acima. Para o réu Bruno fica fixada em 8 dias-multa e para o réu Gabriel 10 dias-multa.

Sendo o réu Bruno primário e não tendo maus antecedentes, pode ser substituída a pena acima por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

O réu Gabriel deve iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Isso porque embora reincidente e maus antecedentes, e ainda considerando a notícia de falta disciplinar em 21/03/2019 (fls. 122/162), a prisão preventiva dele perdurou de 11/10/2018 a 02/09/2019 (fls. 199/201), período suficiente para que pudesse progredir de regime, tendo em vista a reincidência por crime não violento, nos termos do artigo 112, II da LEP.

Na ausência de Casa do Albergado, ele deverá comparecer mensalmente em juízo para comprovar e justificar as suas atividades.

A pena de multa a ser paga pelos réus deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Considerando o que foi dito acima acerca da condição econômico-financeira dos réus, mantenho o valor da pena de multa no patamar mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu GABRIEL MOROZESKY PIMENTA, qualificado nos autos, artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal para comprovação e justificação das atividades; e o réu BRUNO DOS SANTOS SILVA, como incurso(a) no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, o que fica substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 8 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo;

À vista da sanção fixada para cada um dos réus, permito que eles permaneçam em liberdade.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados. Oficie-se à OAB para remuneração dos patronos dos réus, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA